

第71問

甲は、乙と不倫していることが妻であるAに発覚してしまったことから、A及び乙と3人で話し合う機会を設けることとした。甲は、話合いが行われる前に、乙に対し、「Aは、感情的になると何をするのか分からない。Aが暴れそうな素振りをみせたら、思い切った対応が必要になる。」などと、暗にAに暴力を振るうことを提案したところ、乙は甲の意図を察した上で「仕方ないと思うわ。」などと了承した。この時、甲は場合によっては、Aを殺してしまっても仕方がないと考えていたが、乙はAを殺すつもりはなかった。

Aは、話合いの場において、声を荒らげて乙を罵倒し始めたことから、甲と乙で、Aを取り押さえた上で、テーブルを背にしたAを思い切り突き飛ばした。その結果、Aは、テーブルの角に頭部を殴打し、頭部挫傷により死亡した。なお、後日、Aの死因である頭部挫傷は、乙の暴行から生じたことが判明している。

甲は、乙をかばうため、自己が所有する別荘に乙をかくまった。その上で、Aと乙の関係が警察に発覚しないようにするため、甲や乙と不倫発覚後にやりとりをしていたAの携帯電話を処分した。

甲及び乙の罪責について、論じなさい。

第1 甲の罪責

- 1 甲はAを、殺意をもって死亡させているから、殺人罪（199）の罪責を負うことが考えられる。

もっとも、共同正犯（60）関係にある乙は、殺意がなく、また、Aの死の結果は乙の暴行によって生じていることが明らかとなっているから、甲に成立する犯罪及び乙との共犯関係が成立する範囲が問題となる

（**論点** 共犯と錯誤～共同正犯（共同正犯の本質論）  司H20,H29,R3,I,H5-1,H11-

 154頁  63頁

1,H18-1,H20-1）。

この点について、判例であるとされる部分的犯罪共同説（最決昭54.4.13【百選I92】、最決平17.7.4【百選I6】参照）の立場からすると、甲と乙に傷害致死罪（205）の共同正犯が成立することには争いがない。

もっとも、重い結果が故意ない者の行為から生じた場合の処理については、故意ある者に既遂罪の単独正犯が成立すると解する立場と、未遂罪の単独正犯が成立すると解する立場がある。

前者の立場からは、甲に殺人既遂罪の単独正犯が、後者の立場からは甲に同未遂罪の単独正犯が別途成立する。

- 2(1) 次に、乙をかばうために、自己が所有する別荘に乙をかくまった点について、犯人蔵匿罪（103）の成否が問題となる。

この点について、共犯者は自己の犯罪に関する一種の証拠であるから、自己の犯罪の証拠隠滅として不可罰となるのではないかが問題となる（**論点** 共犯者による蔵匿・隠避）。この点について、旭川地判昭57.9.29【百選II121】は、「共犯者に対する犯人蔵匿、隠避が、行為者である被告人自身の刑事被告事件に関する証拠湮滅としての側面をも併有しているからといって、そのことから直ちにこれを不可罰とすることはできないものと解すべきである。けだし、かように被告人自身の刑事被告事件の証拠方法となるのみならず、終局的には共犯者である犯人自身の刑事被告事件における刑執行の客体ともなる者自体を蔵匿し、隠避せしめて、当該犯人に対する捜査、審判及び刑の執行を直接阻害する行為は、もはや防禦として放任される範囲を逸脱するものというべきであって、自己の刑事被告事件の証拠湮滅としての側面をも併有することが、一般的に期待可能性を失わせる事由とはならない」として、可罰的であるとしている。

 284頁  150頁

- (2) また、Aの携帯電話を処分した点について、証拠隠滅罪（104）の成否が問題となる。

共犯者の刑事事件に関する証拠について隠滅した場合の処理を論じる必要がある（**論点** 共犯者の刑事事件は「他人の刑事事件」（104）に当たるか  司H21,予H29）。

 286頁  151頁

なお、この点について仮に不可罰とした場合であっても、犯人隠避罪（103）の成立可能性は残るだろう（もっとも、典型的な証拠隠滅行為については、犯人隠避罪の成否は問題としないのが一般的である。）。

証拠隠滅罪と犯人隠避罪の双方の成立を認めた場合には、それらは観念的競合となろう。

- 3 別荘に乙を匿った点について犯人蔵匿罪を、Aの携帯を処分した点に

ついて証拠隠滅罪（及び/又は犯人隠避罪）の成立を認めた場合、保護法益に対する理解とも相まって、併合罪とする見解と包括一罪とする見解があるだろう。

第2 乙の罪責

上記のように、傷害致死罪が成立し、甲と共同正犯となる。

第1 甲の罪責

- 1 甲は、乙と意思を通じた上で、殺意をもってAを突き飛ばし、死亡させているところ、本件では、殺意のない乙の行為によって死の結果が惹起されている

↓

故意ある甲には殺人罪（199）、故意ない乙には傷害致死罪（205）が成立するに止まる

↓

異なる故意犯の間の共同正犯の成立範囲

↓

部分的犯罪共同説

↓

傷害致死罪の限度で共同正犯となる

↓

乙の行為から結果が生じた場合であっても、殺意ある甲には、別途殺人既遂罪の単独正犯が成立する

↓

- 2 自己が所有する別荘に乙をかくまった行為について、犯人蔵匿罪（103）の成否

↓

共犯者の蔵匿は、一種の自己に関する証拠隠滅行為として不可罰である（104参照）以上、犯人蔵匿罪も不可罰となるのではないか

↓

可罰説

↓

犯人蔵匿罪成立

↓

- 3 甲や乙と不倫発覚後にやりとりをしていたAの携帯電話を処分した行為について、証拠隠滅罪（104）の成否

↓

共犯事件に関する証拠は、「他人の刑事事件に関する証拠」に当たるか

↓

専ら共犯者のためにする意思で隠滅した証拠のみ「他人の刑事事件に関する証拠」に当たる

↓

あてはめ

↓

犯人隠避罪成立

↓

- 4 甲に①殺人罪、②犯人蔵匿罪、③犯人隠避罪が成立し、全て併合罪（45前段）となる。①については、乙と傷害致死罪の限度で共同正犯となる

第2 乙の罪責

傷害致死罪の共同正犯が成立する

第1 甲の罪責

1 甲は、乙と意思を通じた上で、殺意をもってAを突き飛ばし、死亡させているところ、本件では、殺意のない乙の行為によって死の結果が惹起されている。このような場合、甲をいかにして処断すべきか。

(1) まず前提として、甲は殺人の故意を有しているが、乙は傷害の故意を有するにとどまっている。そのため、甲には殺人罪（199条）が成立し得る一方で、乙には傷害致死罪（205条）が成立するにとどまる（38条1項、2項）。

このように共犯者間で成立する罪名が異なる場合、そもそも共同正犯（60条）が成立するのか。

相互利用補充関係に基づく共同犯行の一体性という共同正犯の性質からすれば、共同正犯が成立するためには、共同して特定の構成要件を実現したという事実を要するというべきである。すなわち、「犯罪」とは特定の構成要件の実現を意味すると解すべきである。

そうすると、共同正犯間の故意が異なる場合、共同正犯が成立しないとも考えられる。

しかし、構成要件的に重なり合う範囲については「犯罪」の「共同」が認められる。

したがって、そのような限度で共同正犯の成立が認められるというべきである。

殺人罪と傷害致死罪では、傷害致死罪の限度で構成要件的な重なり合いが認められるから、その限度で共同正犯が成立し、殺意のある甲

1

には殺人罪の既遂又は未遂の単独犯が別途成立すると考えられる。

(2) ここで、重い結果が故意ない者の行為から生じた場合の処理について、故意ない者の行為から結果が発生している以上、単独犯として見た場合には、因果関係が否定され、未遂犯が成立するにとどまるとする立場がある。

しかし、重い故意を有した上で、重い結果と共犯としての因果性がある者を殺人既遂としない点で、かかる処理は実態にそぐわない。

そこで、このような場合でも、重い故意を有する者には、単独正犯の既遂が成立するというべきである。

(3) 以上から、甲には殺人既遂罪の単独正犯が成立し、傷害致死罪の限度で乙と共同正犯となる。

2(1) 次に、乙をかばうため、自己が所有する別荘に乙をかくまった行為について、犯人蔵匿罪（103条）の成立が考えられる。

甲は、傷害致死罪という「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」乙を「蔵匿」しているから、犯人蔵匿罪の構成要件に該当する。

(2) もっとも、本件では、甲と乙は共犯者であり、共犯者は自己にとっての一種の「証拠」であるから、甲にとって乙を蔵匿することは、自己の刑事事件に関する証拠隠滅に当たるとみることができる。このような犯人自身による証拠隠滅行為は不可罰である（104条）以上、犯人蔵匿罪との関係においても、不可罰であるとも考えられる。

しかし、犯人が共犯関係にある者を蔵匿して当該犯人に対する捜査・審判・刑の執行を直接阻害する行為は防御権の範囲を逸脱する。

2

また、犯人自身による証拠隠滅が不可罰であるのは期待可能性がない点に根拠があるが、この場合は期待可能性を失わせるものとはいえない。さらに、蔵匿行為の方が国家の刑事司法作用を害する程度が高いということもできる。

したがって、共犯者を蔵匿する場合であっても、犯人蔵匿罪が成立する。

(3) よって、甲には犯人蔵匿罪が成立する。

3(1) また、甲がAと乙の関係が警察に発覚しないようにするため、甲や乙と不倫発覚後にやりとりをしていたAの携帯電話を処分した行為について、「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅」したとして、証拠隠滅罪(104条)の成立が考えられる。

(2) では、共犯の場合、その事件に関する証拠は「他人の刑事事件に関する証拠」(104条)に当たるといえるか。

104条で「他人の」とされている理由は被疑者、被告人には証拠を隠滅しないことに期待可能性がないからであるところ、共犯事件に関する証拠には専ら他人のための証拠も含まれており、これの隠滅に期待可能性がないとはいえない。そうすると、期待可能性ある場合も含め、全て自己の刑事事件の証拠とするのは本条の趣旨に反する。自己の被告事件と関係ない証拠は、上記にいう他人の刑事事件の証拠とすべきである。

したがって、専ら共犯者のためにする意思で隠滅した証拠のみ「他人の刑事事件に関する証拠」に当たるとすべきである。

3

(3) 本件では、甲は乙をかばうため、Aと乙の関係の発覚を防ごうとAの携帯電話を処分しているから、専ら乙のために隠滅しているとも思える。

しかし、Aと乙の関係が発覚するということは、すなわち、甲と乙の不倫関係が発覚してしまうことを意味しており、Aの携帯電話に記録された不倫発覚後のやり取りを参照すれば、それが明らかになるおそれがある。そうだとすれば、自己のためにも証拠を隠滅したと考えるのが素直である。

したがって、甲がAの携帯電話を処分した行為について、証拠隠滅罪は成立しない。

(4) もっとも、甲には犯人隠避罪が成立する。「隠避」(103条)とは、蔵匿以外の方法により官憲の逮捕・発見を妨げる一切の行為をいうところ、証拠を隠滅することもこれに含まれるからである。

なお、上記のように、104条で不可罰であるからといって、必ずしも103条で不可罰になるとは限らない。

4 以上より、甲に①殺人罪、②犯人蔵匿罪、③犯人隠避罪が成立し、全て併合罪(45条前段)となる。また①については、乙と傷害致死罪の限度で共同正犯となる。

第2 乙の罪責

乙には、上述のとおり傷害致死罪が成立し、甲と共同正犯となる。

以上

4